Nachholprüfung Assessmentjahr – Sommer 2023

Teil Prof. Cueni

Name: | **Vorname:**

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Raphaela Cueni (90 Minuten)**

Verantwortlich: Prof. Dr. Stefan G. Schmid

Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst **4 Aufgaben auf 11 Seiten** (inkl. dieses Deckblatts). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

1. Aufgabe	30 Punkte
2. Aufgabe	23 Punkte
3. Aufgabe	17 Punkte
4. Aufgabe	20 Punkte
Total	**90 Punkte**

Schreiben Sie direkt auf die Antwortblätter; sollten Sie Zusatzblätter benötigen, verwenden Sie bitte für jede Aufgabe ein separates Blatt.
Begründen Sie jede Antwort und nennen Sie die einschlägigen Rechtsnormen!

Aufgabe 1 — 30 Punkte

Frage 1: [7 Punkte]

Nach welcher Methode werden Verfassungsbestimmungen grundsätzlich ausgelegt?

Grundsätzlich wird Verfassungsrecht nach der gleichen Methode ausgelegt wie anderes Recht auch (**1 Punkt**). Es wird also der Text der Verfassung (*grammatikalisches* Auslegungselement) konsultiert (**1 Punkt**). Hierbei sind alle Amtssprachen als gleichwertig anzusehen (**1 Bonuspunkt**). Unklarheiten werden anhand der Entstehungsgeschichte (*historisches* Auslegungselement) (**1 Punkt**) sowie der Stellung der Norm innerhalb der Verfassung und der Rechtsordnung überhaupt (*systematisches* Auslegungselement) (**1 Punkt**) beseitigt. Bei der historischen Auslegung werden die Materialien beigezogen (**1 Bonuspunkt**). Zudem ist der mit der Norm verfolgte Normzweck zu berücksichtigen (*teleologisches* Auslegungselement) (**1 Punkt**). Das Bundesgericht wendet zur Auswahl dieser Methoden den sogenannten *pragmatischen Methodenpluralismus* (**1 Punkt**) an: Es lehnt eine Priorisierung der Methoden ab und wendet sie in der Kombination an, die der Falllösung entspricht, d.h. am besten auf den Einzelfall zugeschnitten ist (**1 Punkt**).

Frage 2: [3 Punkte]

Welche Eigenheiten der Verfassung sind bei der Auslegung von Verfassungsnormen zu berücksichtigen? Nennen Sie drei.

Die Verfassung unterscheidet sich von einem «normalen» Gesetzestext mitunter durch (**je 1 Punkt, max. 3 Punkte**):

- die Offenheit der Normen
- die mitunter durch Volksinitiativen entstehenden Widersprüche zwischen den Normen
- das damit einhergehende unterschiedliche Alter der verschiedenen Normen
- die fragliche Justiziabilität der Normen
- die sprachliche und inhaltliche Heterogenität der Normen

Vgl. Reader § 2, Rz. 45 ff. / Fragenkatalog 2

Frage 3: [11 Punkte]

Wie wirken sich diese Eigenheiten auf die Auslegung der Verfassung aus?

[Verschiedene Antworten möglich, je nach Eigenheiten, die in Frage 2 genannt wurden!]

Die Möglichkeit der jederzeitigen Abänderbarkeit der Verfassung (durch Volksinitiativen) kann dazu führen, dass aus einem aktuellen Anlass eine einzelne Bestimmung in die Verfassung eingefügt wird, die anderen Verfassungsnormen widerspricht. Im Rahmen der *systematischen* Auslegung (**1 Punkt**) ist deshalb darauf zu achten, dass die Verfassungsbestimmungen in *praktische Konkordanz* (**1 Punkt**) gebracht werden. D.h. dass durch eine harmonisierende Auslegung Widersprüche innerhalb der Verfassung zu minimieren sind (Harmonisierung) (**1 Punkt**), und dass nach Möglichkeit Verfassungsbestimmungen in Übereinstimmung mit völkerrechtlichen Bestimmungen ausgelegt und damit Widersprüche zwischen Verfassungsrecht und Völkerrecht minimiert werden (völkerrechtskonforme Auslegung) (**2 Punkte**). Es besteht hier aber die Gefahr, dass bewusst in Kauf genommene Konflikte entgegen dem Normsinn «wegharmonisiert» werden und eine wertende Normenhierarchie geschaffen wird (**1 Punkt**).

Es kann sein, dass bei der Auslegung dennoch festgestellt wird, dass sich Verfassungsnormen *widersprechen*. Mit diesem Konflikt kann auf zwei Arten umgegangen werden. Zum einen können die üblichen Kollisionsregeln angewendet werden, nämlich dass neueres Recht älterem vorgeht (*lex posterior derogat legi priori*) (**1 Punkt**) und dass die generellere Norm hinter die Spezialbestimmung zurücktreten muss (*lex specialis derogat legi generali*) (**1 Punkt**). Da aber nach herrschender Lehre keine Rangabstufung zwischen verschiedenen Verfassungsbestimmungen besteht, können solche Kollisionsregeln höchstens in klaren Fällen weiterhelfen (**1 Punkt**).

Je nach Flexibilität der Verfassung sind die Normen zudem sehr alt. Bei der Auslegung ist deshalb zu überlegen, ob einer Norm durch *historische* (d.h. streng auf die Auffassung beim Erlass der Norm abstellende) oder durch *zeitgemässe* (d.h. auf die heutige Situation angepasste) Auslegung eine adäquatere Antwort auf aktuelle Problemstellungen entnommen werden kann (**2 Punkte**).

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Anlässlich der Spiele seines Fussballclubs verkleidet sich Max jeweils als dessen Maskottchen. Er feuert von der Seitenlinie die Mannschaft an und steht für Fotos mit Fans zur Verfügung. Obschon ihm das Bewegen und Atmen in diesem Ganzkörperanzug, der auch sein Gesicht bedeckt, schwerfällt, übernimmt er die Aufgabe gerne.

Nachdem das Schweizer Stimmvolk am 7. März 2021 die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» angenommen hat, womit die Bundesverfassung um Art. 10*a* BV

ergänzt wurde, macht sich Max Sorgen, dass er seiner Tätigkeit als Maskottchen nicht mehr nachgehen kann. Max weiss, dass Sie sich mit der Auslegung der Bundesverfassung hervorragend auskennen, und wendet sich an Sie.

Frage 4: [9 Punkte]

Stellt die Verkleidung von Max als Maskottchen anlässlich von Fussballspielen eine im Sinne von Art. 10*a* BV verbotene Gesichtsverhüllung dar? Argumentieren Sie unter Zuhilfenahme der Ihnen bekannten Auslegungsmethoden.

Hinweis: *Das historische Auslegungselement dürfen Sie für die Beantwortung dieser Frage ausklammern.*

Verschiedene Antworten möglich: je max. 2 Punkte für eine schlüssige Argumentation pro Auslegungselement (**max. 7.5 Punkte**) / **1.5 Punkte** für ein nachvollziehbares Fazit / **Bonuspunkte** für Beizug verfassungsspezifischer Auslegungselemente

Aufgabe 2 — 23 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Anna ist Nationalrätin und Verwaltungsratspräsidentin der Frimsel Kraftwerke AG, die im Kanton X. ein Wasserkraftwerk am Frimselstausee betreibt. Schon seit Jahren will die Frimsel Kraftwerke AG die Frimselstaumauer erhöhen. Da am Ufer des Frimselstausees aber seltene Pflanzen und Wälder wachsen, konnten sich Naturschutzverbände bisher erfolgreich gegen eine Erhöhung wehren. Vor kurzem wurde im Kanton X. gar das kantonale Waldgesetz totalrevidiert, womit sämtliche grösseren Bauvorhaben rund um das Wasserkraftwerk am Frimselstausee verunmöglicht wurden.

Anna ist mit ihrer Geduld am Ende und möchte im Nationalrat einen Vorstoss zur Totalrevision des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) gestützt auf Art. 77 BV lancieren.

Frage 1: [3 Punkte]

Äussern Sie sich zunächst allgemein zur Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen.

Nach dem Grundsatz der Einzelermächtigung des Bundes durch die Bundesverfassung (Art. 42 Abs. 1 BV) (**1 Punkt**) ist der Bund in einem Sachbereich nur zuständig, wo und soweit die Bundesverfassung dem Bund eine Kompetenz ausdrücklich zuweist (**1 Punkt**). Ansonsten bleiben aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3 BV) die Kantone zuständig (**1 Punkt**).

Frage 2: [9 Punkte]

Begründet Art. 77 BV eine Bundeskompetenz? Qualifizieren Sie gegebenenfalls nach Umfang und Wirkung.

Art. 77 Abs. 1 BV ist eine Zielnorm (**1 Punkt**), die keine Verbandskompetenz des Bundes begründet (**1 Punkt**).

Art. 77 Abs. 2 BV begründet eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz des Bundes (**1 Punkt**). Art. 77 Abs. 3 BV begründet eine Förderungskompetenz des Bundes (**1 Punkt**). Darauf deuten der Wortlaut und die Stellung in der Verfassung hin (**1 Punkt**). Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz in Abs. 2 ist nachträglich derogatorisch (**1 Punkt**), was dem Normalfall entspricht (**1 Punkt**). Die Förderungskompetenz in Abs. 3 ist parallel (**1 Punkt**), da es dem Sinn und Zweck der Norm widersprechen würde, wenn nur der Bund Massnahmen zur Erhaltung des Waldes ergreifen könnte (**1 Punkt**).

Sachverhaltsfortsetzung:

Peter, ebenfalls Nationalrat und Naturfreund, hatte sich demgegenüber sehr gefreut, dass im Kanton X. der (Um-)Bau von Kraftwerken zum Schutz der Natur durch die Revision des kantonalen Waldgesetzes weitgehend eingeschränkt wurde. Er ist der Meinung, dass ein solches Verbot für die gesamte Schweiz und für alle möglichen Bauten gelten sollte. Schon lange ist es ihm ein Dorn im Auge, dass die Kantone im Bereich des Bauwesens weitgehend freie Hand haben, da er der Auffassung ist, der Naturschutz komme hierbei nicht selten zu kurz.

Peter möchte seine Kollegen im Nationalrat davon überzeugen, mittels einer Totalrevision des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) sowie des Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG) die Raumplanung und den Natur- und Heimatschutz umfassend auf Bundesebene zu regeln und die kantonalen Kompetenzen in diesen Bereichen auf ein Minimum zu begrenzen.

Frage 3: [11 Punkte]

Ist Peters Vorhaben mit der geltenden verfassungsmässigen Ordnung zu vereinbaren?

Art. 75 Abs. 1 und 2 begründen je eine Verbandskompetenz des Bundes (**1 Punkt**) im Bereich der Raumplanung, welche sich aber auf die Grundsatzgesetzgebung (**1 Punkt**) bzw. auf die Förderung und Unterstützung (**1 Punkt**) beschränken. Darauf deutet der Wortlaut hin (**1 Punkt**).

Für den Natur- und Heimatschutz sind aufgrund ihrer subsidiären Generalkompetenz (Art. 3 i.V.m. 42 Abs. 1 BV) grundsätzlich die Kantone zuständig. Art. 78 Abs. 1 BV hält dies ausdrücklich fest, ist aber bloss deklaratorischer Natur (**1 Bonuspunkt**). Demgegenüber begründen Art. 78 Abs. 3 und 4 BV je eine Verbandskompetenz des Bundes (**1 Punkt**) im Bereich des Natur- und Heimatsschutzes. Abs. 3 begründet eine Förderungs- und Unterstützungskompetenz im gesamten Bereich des Natur- und Heimatschutzes (**1 Punkt**) sowie eine fragmentarische Kompetenz zur Sicherung und Erwerbung von Objekten von gesamtschweizerischer Bedeutung (**1 Punkt**). Abs. 4 begründet demgegenüber eine umfassende Gesetzgebungskompetenz betreffend den Tier- und Pflanzenschutz (**1 Punkt**). Darauf deutet ebenfalls der Wortlaut hin (**1 Punkt**).

Weder Art. 75 Abs. 1 und 2 noch Art. 78 Abs. 3 und 4 BV ermächtigen den Bund, die Raumplanung sowie den Natur- und Heimatschutz umfassend zu regeln (**1 Punkt**). Da dem Bund diese Kompetenzen auch nicht durch andere Normen der BV eingeräumt werden, ist Peters Vorhaben nicht mit der verfassungsmässigen Ordnung zu vereinbaren (**1 Punkt**).

Aufgabe 3 — 17 Punkte

Die Nationalratswahlen vom Herbst 2023 führten deutlich vor Augen, was sich im Kanton Zürich schon seit längerem abzeichnet: Während die Stimmbevölkerung der Stadt Zürich überwiegend Parteimitglieder der politischen Linken unterstützte, war die politisch am rechten Ufer angesiedelte «Schweizerische Volkspartei» (SVP) in den ländlicheren Kantonsgebieten eindeutig die wählerstärkste Partei. Dieser sogenannte «Stadt-Land-Graben» hat zur Folge, dass Anliegen der politisch linken Parteien durch die Wählerinnen und Wähler der politisch rechten Parteien (und ebenso umgekehrt) ausgebremst werden können. Um dem entgegenzuwirken, sprechen sich immer wieder Stimmen aus beiden politischen Lagern für eine Abspaltung der Stadt Zürich vom restlichen Kanton aus, wobei an die Stelle des heutigen Kantons Zürich zwei sogenannte «Halbkantone» – Zürich-Stadt und Zürich-Land – treten würden.

Frage 1: [9 Punkte]

Welche Anforderungen stellt die Bundesverfassung an eine Aufspaltung des Kantons Zürich in zwei sogenannte «Halbkantone»?

Eine Aufspaltung des Kantons Zürich in zwei sog. Halbkantone würde den Bestand der Kantone ändern (**1 Punkt**). Eine Bestandesänderung ist unter den Voraussetzungen von Art. 53 Abs. 2 BV (**1 Punkt**) zulässig:

1) Zustimmung der betroffenen Bevölkerung (**1 Punkt**) + Subsumtion (½ **Punkt**)
2) Zustimmung der unmittelbar betroffenen Kantone (**1 Punkt**)
   + Subsumtion (½ **Punkt**)
3) Zustimmung von Volk und Ständen (**1 Punkt**)

Zudem müsste Art. 1 BV geändert werden, da dieser die einzelnen Kantone aufführt (**1 Punkt**). Da sich die Anzahl der Ständeratssitze nicht verändern würde, muss Art. 150 Abs. 1 BV nicht geändert werden (**1 Bonuspunkt**, sofern in Frage 2 nicht genannt).

Alle Änderungen der Bundesverfassung unterstehen dem obligatorischen Referendum mit Doppelmehrerfordernis (vgl. Art. 140 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 142 Abs. 2 BV) (**1 Punkt**). Die im Rahmen von Art. 53 Abs. 2 BV erforderliche Zustimmung von Volk und Ständen und die übrigen Verfassungsänderungen können daher in derselben Abstimmung erfolgen (**1 Punkt**).

Frage 2: [2 Punkte]

(Inwiefern) Ändert sich Ihre Antwort aus Frage 1, wenn Zürich-Stadt und Zürich-Land nicht zu sogenannten «Halbkantonen», sondern zu zwei «vollen» Kantonen werden?

In diesem Fall ändert sich darüber hinaus die Anzahl der Ständeratssitze (**1 Punkt**), womit Art. 150 Abs. 1 BV ebenfalls abgeändert werden müsste (**1 Punkt**).

Der nachfolgende Sachverhalt ist frei erfunden:

Einzelne ländlichere Gemeinden des Kantons Zürich stehen einer Aufspaltung kritisch gegenüber. Sie sind besorgt, dass gerade kleinere Gemeinden nach einer Aufspaltung aus Kostengründen fusioniert werden müssten.

Frage 3: [6 Punkte]

Inwiefern schützt die Bundesverfassung die Gemeinden des Kantons Zürich vor Gemeindefusionen?

Die Bundesverfassung gewährleistet die Gemeindeautonomie nach Massgabe des kantonalen Rechts (Art. 50 Abs. 1 BV) (**1 Punkt**). Gewährleistung bedeutet in diesem Zusammenhang, dass eine Gemeinde im Fall einer Verletzung ihrer durch das kantonale Recht gewährten Autonomie das Bundesgericht anrufen kann (**1 Punkt**) (Art. 189 Abs. 1 lit. e BV; **1 Punkt**). Der rechtliche Beitrag des Bundes erschöpft sich allerdings darin, die Gemeindeautonomie in dem vom kantonalen Recht bestimmten Umfang unter eidgenössischen Gerichtsschutz zu stellen (**1 Punkt**). Da die Bundesgarantie nur greift, sofern das kantonale Recht den Gemeinden Autonomie zugesteht, handelt es sich ausschliesslich um eine formale (und keine materielle oder inhaltliche) Garantie (**1 Punkt**). Die Bundesverfassung schützt die Zürcher Gemeinden daher nur so weit, wie sich ihre Autonomie aus dem kantonalen Recht ergibt (**1 Punkt**).

Aufgabe 4 — 20 Punkte

Der Sachverhalt ist frei erfunden!

Leo besuchte das Assessmentjahr an der Universität Zürich. Ihm wurde nach dem zweiten Semester eine ungenügende Note für die Prüfung im Fach «Mathematik» verfügt, womit Leo nicht zum Bachelorstudium zugelassen wäre und sämtliche Leistungen des ersten Studienjahres wiederholen müsste.

An der Prüfungseinsicht sah Leo, dass er für eine Aufgabe, für die 30 von 180 Punkten erzielt werden konnten, nur 2 Punkte erhielt. Er ist der Meinung, die Aufgabe mit viel Kreativität gelöst und daher die volle Punktzahl verdient zu haben. Die Korrektur erfolgte in seinen Augen willkürlich. Die mit der Organisation der Prüfungseinsicht betraute Assistentin zeigte ihm zwar seine Prüfung, verweigerte ihm jedoch die Einsicht in die Dokumente, welche die Korrekturkriterien nennen (insb. Musterlösung). Leo möchte sich gegen die ungenügende Note im Fach «Mathematik» wehren und einen Rekurs bei der universitätsinternen Rekurskommission einlegen.

Frage 1: [2 Punkte]

Hat Leo gestützt auf die Bundesverfassung einen Anspruch auf Herausgabe der Musterlösung?

Ja. Das Recht aus Akteneinsicht ergibt sich aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör **(1 Punkt**) gemäss Art. 29 Abs. 2 BV (**1 Punkt**).

Frage 2: [2 Punkte]

Hat Leo gestützt auf die Bundesverfassung einen Anspruch, sich im universitätsinternen Rekursverfahren anwaltlich vertreten zu lassen?

Ja. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) (**1 Punkt**) wird der Anspruch abgeleitet, sich in Gerichts- und Verwaltungsverfahren vertreten zu lassen (**1 Punkt**).

Frage 3: [2 Punkte]

Leo möchte gerne, dass seine Freunde ihn im Verfahren vor der universitätsinternen Rekurskommission unterstützen können, weshalb er möchte, dass das Verfahren mündlich und öffentlich durchgeführt wird. Gewährt ihm die Bundesverfassung einen solchen Anspruch?

Nein. Ein Anspruch auf Öffentlichkeit besteht nur für Gerichte (Art. 30 Abs. 3 BV) (**1 Punkt**). Bei der universitätsinternen Rekurskommission handelt es sich nicht um ein Gericht, weshalb nur die Minimalgarantien von Art. 29 BV zur Anwendung gelangen (**1 Punkt**). Der Anspruch auf Mündlichkeit besteht zudem nur in Verfahren nach Art. 6 EMRK (**1 Bonuspunkt**).

Frage 4: [12 Punkte]

Verschafft eine Verfahrensgarantie aus der Bundesverfassung Leo einen Anspruch darauf, gerichtlich gegen seine Note vorzugehen?

Für den vorliegenden Fall einschlägig ist die Rechtsweggarantie in Art. 29*a* BV (**1 Punkt**). Adressat dieses Grundrechts ist die Universität Zürich (½ **Punkt**), die als staatliche Behörde ein zulässiger Grundrechtsadressat ist (½ **Punkt**). Auf die Rechtsweggarantie können sich sowohl natürliche wie auch juristische Personen berufen (½ **Punkt**). Leo ist also Träger des Grundrechts (½ **Punkt**).

In sachlicher Hinsicht verlangt Art. 29*a* BV, dass eine Rechtsstreitigkeit vorliegt (½ **Punkt**), die nicht ausnahmsweise gesetzlich ausgeschlossen ist (½ **Punkt**). Eine Rechtsstreitigkeit liegt vor, wenn ein Sachverhalt vom Verfassungs-, Gesetzes- und/oder Verordnungsrecht erfasst wird oder ein Beschwerdeführer dies behauptet und wenn es um Interessen geht, die vom Recht als «schützenswert» anerkannt sind (**1 Punkt**). Solche Interessen sind z.B. anzunehmen, wenn dem betroffenen Privaten Pflichten auferlegt oder Rechte eingeräumt/verweigert werden (**1 Punkt**). Leo macht geltend, die Korrektur sei willkürlich erfolgt, wodurch Art. 9 BV verletzt wäre (**1 Punkt**). Damit ist der vorliegende Sachverhalt rechtlich erfasst (**1 Punkt**). Leo ist in seinen rechtlich geschützten Interessen tangiert (**1 Punkt**), da ihm die ungenügende Note die Weiterführung des Studiums verunmöglicht (**1 Punkt**). Den aufgeführten Bestimmungen und dem Sachverhalt ist zudem nicht zu entnehmen, dass die richterliche Beurteilung ausnahmsweise ausgeschlossen wäre (**1 Punkt**).

Fazit: Art. 29*a* BV kommt daher zur Anwendung und verschafft Leo einen Anspruch darauf, den Entscheid gerichtlich überprüfen zu lassen (**1 Punkt**).

Frage 5: [2 Punkte]

Hat Leo einen verfassungsmässigen Anspruch auf Beurteilung der Notenverfügung durch das Bundesgericht?

Nein. Die Rechtsweggarantie nach Art. 29a BV (**1 Punkt**) gewährt nur einen Anspruch auf ein unabhängiges Gericht, nicht aber auch höchstrichterlichen Rechtsschutz (**1 Punkt).**

Universität St.Gallen

Prüfungsbooklet Assessment

Rechtswissenschaft I B

Teil Schmid

Hinweise:

- **Die alten Prüfungen dienen als Lernhilfe.**
- **Die Musterlösungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.**
- **Die zitierten Stellen des Lehrbuchs oder die angegebenen Folien beziehen sich auf die zum Prüfungszeitpunkt aktuelle Auflage bzw. aktuelle Vorlesungsstruktur.**

Universität St.Gallen

Prüfung Assessmentjahr – Frühjahrssemester 2023

Name: _____ **Vorname:** _____

Muttersprache(n): Matrikel-Nr.:

Prüfungsfach: **Rechtswissenschaft I B (schriftliche Prüfung)**

2,170

Prüfungsteil: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid (90 Minuten)**

Verantwortlich: **Prof. Dr. Stefan G. Schmid**

Bemerkungen:

Dieser Prüfungsteil umfasst 4 Aufgaben auf 21 Seiten (inkl. dieses Deckblatts). Die Punkte verteilen sich folgendermassen auf die einzelnen Aufgaben:

Aufgabe 1	30 Punkte
Aufgabe 2	10 Punkte
Aufgabe 3	20 Punkte
Aufgabe 4	30 Punkte
Total	**90 Punkte**

Wichtige Hinweise:

Bitte beachten Sie bei der Bearbeitung dieser Prüfung folgende Hinweise:

1. Verwenden Sie für die Lösungen den freigehaltenen Platz unterhalb der Fragen. Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht genügen, bitten Sie die Prüfungsaufsicht um ein Zusatzblatt. Verwenden Sie für jede Aufgabe ein neues Zusatzblatt und kennzeichnen Sie genau, um welche Aufgabe in welchem Teil der Prüfung es sich handelt. Schreiben Sie auf jedes Zusatzblatt Ihren Namen sowie Ihre Matrikelnummer und nummerieren Sie die Blätter.
2. **Begründen Sie alle Antworten und nennen Sie, wo vorhanden, die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen.**
3. Bitte formulieren Sie **ganze Sätze** und versuchen Sie, Ihre Ausführungen strukturiert und übersichtlich aufzubauen. Achten Sie auf eine leserliche Handschrift.

Aufgabe 1: «Klimafonds-Initiative» (30 Punkte)

Politikerinnen und Politiker der GRÜNEN Schweiz sowie der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz (SP Schweiz) haben dem Klimawandel den Kampf angesagt: Sie finden, dass es kurzfristig massive Investitionen brauche, um den Klimaschutz zu stärken und gleichzeitig unsere Energie weitestgehend selbst produzieren zu können. Deshalb haben sie eine eidgenössische Volksinitiative mit dem Titel «Für eine gerechte Energie- und Klimapolitik: Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt (Klimafonds-Initiative)» lanciert.

Die Volksinitiative hat folgenden Wortlaut:

> Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
>
> **Art. 103*a*** Förderung einer sozial gerechten Energie- und Klimapolitik
>
> [1] Bund, Kantone und Gemeinden bekämpfen die menschengemachte Klimaerwärmung und ihre gesellschaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Folgen in Übereinstimmung mit den internationalen Klimaabkommen. Sie sorgen für eine sozial gerechte Finanzierung und Umsetzung der Massnahmen.
>
> [2] Der Bund unterstützt insbesondere:
> a. die Dekarbonisierung von Verkehr, Gebäuden und Wirtschaft;
> b. den sparsamen und effizienten Energieverbrauch, die Versorgungssicherheit und den Ausbau der erneuerbaren Energien;
> c. die notwendigen Aus-, Weiterbildungs- und Umschulungsmassnahmen inklusive finanzielle Beiträge für den Ausgleich des Einkommensausfalls während der Ausbildungszeit;
> d. nachhaltige und natürliche Karbonsenken;
> e. die Stärkung der Biodiversität, namentlich zur Bekämpfung der Folgen der Klimaerwärmung.
>
> [3] Für die Finanzierung der bundeseigenen Vorhaben und für finanzielle Beiträge an die Vorhaben von Kantonen, Gemeinden und Dritter verfügt der Bund über einen Investitionsfonds. Der Fonds oder vom Bund beauftragte Dritte können auch Kredite, Garantien und Bürgschaften gewähren.
>
> [4] Das Gesetz regelt die Einzelheiten.

Frage 1)
Prüfen Sie, ob die «Klimafonds-Initiative» die Gültigkeitsvoraussetzung der Einheit der **Form** erfüllt. (8 Punkte)

Einheit der Form (Art. 139 Abs. 3, Art. 194 Abs. 3 BV; Art. 75 Abs. 1 BPR):
Die Volksinitiative muss entweder vollständig als ausgearbeiteter Entwurf oder vollständig als allgemeine Anregung vorliegen (Art. 139 Abs. 2 BV).
- Ein ausgearbeiteter Entwurf wird wortwörtlich in die Bundesverfassung aufgenommen, wenn die Volksinitiative in der Abstimmung angenommen wird.
- Eine allgemeine Anregung hingegen ist so formuliert, dass der Text nicht direkt in die Bundesverfassung übernommen werden soll. Sie stellt vielmehr eine verpflichtende Anregung an die Bundesversammlung dar, einen oder mehrere Verfassungsartikel im Sinne der Volksinitiative auszuarbeiten. Sie enthält eine Leitidee und gibt dem Parlament Spielraum bei der

Ausarbeitung der Formulierung. Allerdings können in allgemeine Anregungen durchaus auch detailliertere Weisungen aufgenommen werden, wobei sie sich dann einem ausgearbeiteten Entwurf annähern.

In casu: Es handelt sich um einen ausgearbeiteten Entwurf, da der Text genau so in die Bundesverfassung aufgenommen werden kann. Die Tatsache, dass einige Absätze eher offen formuliert sind und auf Gesetzesstufe noch konkretisiert werden müssen, ist für die Verfassungsstufe nicht unüblich und stellt noch längst keine Formvermischung dar.

Fazit: Die Einheit der Form ist demnach gewahrt.

GIOVANNI BIAGGINI/THOMAS GÄCHTER/REGINA KIENER (Hrsg.), Staatsrecht, 3. Aufl., Zürich/St.Gallen 2021, § 23 N. 70, 96 u. 100.

Frage 2)
Die Bundesversammlung nimmt die Prüfung, ob eine Volksinitiative die Gültigkeitsvoraussetzungen erfüllt, bekanntlich erst vor, nachdem die notwendigen 100'000 Unterschriften bereits gesammelt worden sind.

a) In welcher Erlassform ergeht der Entscheid über die Gültigkeit einer Volksinitiative? Kann dagegen ein Referendum ergriffen werden? (3 Punkte)

Der Entscheid über die Gültigkeit einer Volksinitiative (Art. 173 Abs. 1 Bst. f BV) ergeht in der Erlassform des einfachen Bundesbeschlusses, der nicht dem Referendum untersteht (Art. 163 Abs. 2 BV i.V.m. Art. 29 Abs. 1 ParlG).

Vorlesung V Folie 22
BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 24 N. 22 ff.

b) Kann der Entscheid über die Gültigkeit der Volksinitiative beim Bundesgericht angefochten werden? (2 Punkte)

Nein, eine Überprüfung durch das Bundesgericht ist nicht möglich, da Akte der Bundesversammlung beim Bundesgericht grundsätzlich nicht angefochten werden können und keine gesetzliche Ausnahme vorliegt (Art. 189 Abs. 4 BV).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 78

c) Verschiedentlich wird eine Änderung der Bundesverfassung dahingehend gefordert, dass die Bundesversammlung die Gültigkeitsprüfung bereits **vor** der Unterschriftensammlung vornehmen sollte. Nennen Sie ein Argument für und ein Argument gegen diese Forderung. (4 Punkte)

Pro:

- *Bei einer Gültigkeitsprüfung vor der Unterschriftensammlung sehen sich die Behörden einem weniger starken politischen Druck ausgesetzt, da die erforderlichen Unterschriften noch nicht gesammelt worden sind. Dies vereinfacht eine objektive und rein juristische Beurteilung der Gültigkeit.*
- *Eine frühzeitige Prüfung wäre aus Sicht der Initiantinnen und Initianten effizienter, da sie keine Unterschriften für eine später allenfalls ungültig erklärte Volksinitiative sammeln würden.*

Contra:

- *Die Volksinitiative ermöglicht es, ein beliebiges Anliegen zum Gegenstand des öffentlichen Diskurses zu machen. Eine frühzeitige Prüfung der Gültigkeit könnte den politischen Diskurs vorzeitig beenden.*
- *Bei einer frühzeitigen verbindlichen Prüfung könnten unliebsame Volksinitiativen mit Verweis auf juristische Gründe für ungültig erklärt werden. Damit würden die Volksrechte eingeschränkt.*
- *Eine frühzeitige Prüfung wäre aus Sicht der Behörden wenig effizient, da die meisten Volksinitiativen nicht zustande kommen. Indem nur zustande gekommene Volksinitiativen auf Gültigkeit geprüft werden müssen, wird das Prüfungsorgan vor Überlastung geschützt.*

Vgl. BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 82

Frage 3)

Angenommen, die Mehrheit der Bundesversammlung würde die schliesslich zustande gekommene «Klimafonds-Initiative» für gültig befinden, wäre aber nicht restlos vom Initiativbegehren überzeugt, da ihr die Ziele der Volksinitiative zu weit gehen. Welche Möglichkeiten hätte die Bundesversammlung in der Folge, um auf diese (gültige) Volksinitiative zu reagieren? (7 Punkte)

- *Die Bundesversammlung kann die Volksinitiative ohne Gegenentwurf zur Ablehnung empfehlen (Art. 139 Abs. 5 BV; Art. 100 ParlG).*
- *Die Bundesversammlung kann der Volksinitiative einen direkten Gegenentwurf (Art. 139 Abs. 5 letzter Satz und Art. 139b BV; Art. 76 BPR; Art. 101 ParlG) zur gleichen Verfassungsmaterie gegenüberstellen (Art. 101 Abs. 1 ParlG). Zum gleichen Fragenkreis und auf gleicher Normstufe (Bundesverfassung) wird damit für die Stimmberechtigten eine Alternative geschaffen, die weniger weit geht oder andere Schwerpunkte setzt als die Volksinitiative.*
- *Die Bundesversammlung kann auf die Volksinitiative mit einem indirekten Gegenvorschlag reagieren (vgl. Art. 73a Abs. 2 BPR; Art. 97 Abs. 2 und Art. 105 Abs. 1 ParlG). Ein indirekter Gegenvorschlag steht unterhalb der Verfassungsstufe, hängt mit der Volksinitiative aber eng zusammen. Der indirekte Gegenvorschlag erlaubt es den Behörden, auf das Anliegen der Initiative einzugehen, ohne die Verfassung zu ändern.*

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 23 N. 93, 101 u. 105

Frage 4)

Im Initiativkomitee der «Klimafonds-Initiative» finden sich zahlreiche Mitglieder des Nationalrates, die den im Ausgangssachverhalt erwähnten Parteien angehören. Sie hätten bekanntlich ihr Vorhaben auch direkt in der Bundesversammlung einbringen bzw. eine Verfassungsänderung selbst initiieren können.

a) Welches parlamentarische Handlungsinstrument wäre diesen Mitgliedern des Nationalrates zur Verfügung gestanden, wenn sie eine Ausarbeitung ihrer Vorlage unabhängig vom Bundesrat gewollt hätten? (4 Punkte)

Mit einer parlamentarischen Initiative kann jedes Ratsmitglied (aber auch jede Fraktion oder Kommission) die Ausarbeitung eines Erlasses vorschlagen (Art. 160 Abs. 1 BV; Art. 107 ParlG). Bei einer parlamentarischen Initiative wird der Entwurf für einen Erlass von einer Kommission (Art. 107 ParlG) und somit unabhängig vom Bundesrat ausgearbeitet. Die parlamentarische Initiative wäre für das Vorhaben also geeignet.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 82; § 23 N. 10 ff.

b) Nennen Sie einen möglichen Grund, weshalb sich die GRÜNEN Schweiz und die SP Schweiz im vorliegenden Fall dennoch für eine Volksinitiative und gegen eine Behördenvorlage entschieden haben. (2 Punkte)

Mögliche Antworten:

- *Die Volksinitiative kann als «Wahlhelferin» zur internen Mobilisierung und Selbstinszenierung verwendet werden; sie dient dann dazu, sich (d.h. eine politische Gruppierung oder Partei) ins Rampenlicht zu stellen.*
- *Es besteht die (berechtigte) Befürchtung, dass in der Bundesversammlung keine Mehrheit für dieses Anliegen zustande kommen würde.*

Vgl. zum Beispiel Fragenkatalog 4 Frage 5

Aufgabe 2: Parlamentswörterbuch (10 Punkte)

Nennen Sie den gesuchten Begriff und **eine** dazugehörige Rechtsgrundgrundlage in der Bundesverfassung oder einem Bundesgesetz. (keine Begründung erforderlich)

Beispiel
Das _____ schützt die Ratsmitglieder vor verbindlichen Weisungen. Es verbietet jedoch nicht, dass sich die Ratsmitglieder freiwillig an Abreden halten oder dass sie Interessen vertreten. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Instruktionsverbot (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 161 Abs. 1 BV

Frage 1)
Eine _____ umfasst Angehörige der gleichen Partei oder gleichgesinnter Parteien. Die Bildung ist möglich, wenn mindestens fünf Ratsmitglieder aus einem der beiden Räte beitreten und die Koordinationskonferenz die Genehmigung zur Bildung erteilt. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Fraktion (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 154 BV oder Art. 61 ff. ParlG

Frage 2)
Für Handlungen, welche in unmittelbarem Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit und Stellung stehen, geniessen die Ratsmitglieder und die von der Bundesversammlung gewählten Behördenmitglieder _____ _____. Sie schützt sie vor strafrechtlicher, jedoch nicht vor zivilrechtlicher Verfolgung. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: relative Immunität (2 Wörter)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 17 ParlG oder Art. 162 Abs. 2 BV

Frage 3)
«Ich schwöre vor Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen.» Dies ist die Formel des sogenannten _____. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Amtseides (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 3 Abs. 4 ParlG

Frage 4)
Mit der _____ nimmt das Parlament die politische Kontrolle über Organe des Bundes wahr. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Oberaufsicht (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 169 BV *oder* Art. 26 ParlG

Frage 5)
Mit den _____ verfügt die Bundesversammlung über eine eigene Verwaltung. (2 Punkte)

Gesuchter Begriff: Parlamentsdiensten (1 Wort)

Gesuchte Rechtsgrundlage: Art. 155 BV *oder* Art. 64 ff. ParlG

Aufgabe 3: Ständerat (20 Punkte)

Lesen Sie die folgende Meldung einer Nachrichtenagentur von Mitte Dezember 2022 und beantworten Sie die nachfolgenden Fragen.

Nachfolgerin von Baume-Schneider: Mathilde Crevoisier Crelier ist neue Ständerätin des Kantons Jura

Die 42-jährige Übersetzerin Mathilde Crevoisier Crelier ist neue Ständerätin. Die Sozialdemokratin aus dem Kanton Jura ist am Donnerstagmorgen im Ständerat vereidigt worden. Sie folgt auf die in den Bundesrat gewählte Elisabeth Baume-Schneider.

Crevoisier Crelier wohnt in Pruntrut und wurde dort in diesem Herbst in den Gemeinderat gewählt. Die Abläufe in Bundesbern kennt sie gut, denn sie arbeitet als Übersetzerin im Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI).

Diese Posten gibt sie allerdings Ende Januar auf, wie Ständeratspräsidentin Brigitte Häberli-Koller vor der Vereidigung bekanntgab. […]

Die Nachfolge von Baume-Schneider kann die neue Ständerätin antreten, weil sie bei den Wahlen von 2019 im Kanton Jura nach der designierten Bundesrätin auf dem ersten Ersatzplatz landete. […].

Frage 1)
In der Agenturmeldung wird erwähnt, dass Mathilde Crevoisier Crelier im Ständerat die Nachfolge von Elisabeth Baume-Schneider antreten kann, weil sie bei den Ständeratswahlen von 2019 im Kanton Jura «auf dem ersten Ersatzplatz landete». Welche Besonderheit betreffend die Ständeratswahl im Kanton Jura wird hier angesprochen? (3 Punkte)

Es wird hier die Proporzwahl (= Verhältniswahl) der beiden Mitglieder des Ständerates im Kanton Jura angesprochen, die bis auf den Kanton Neuenburg sonst in keinem anderen Kanton für die Ständeratswahl vorgesehen ist. Da bei einer Proporzwahl die Wählenden nicht für Kandidierende, sondern für Parteilisten stimmen, kann bei einem Ausscheiden eines Mitglieds des Ständerates diejenige Person «nachrutschen», die bei den letzten Wahlen hinter der gewählten und nun ausgeschiedenen Person auf dem ersten Ersatzplatz gelandet ist. Würde der Kanton Jura eine Majorzwahl vorsehen, wäre nach der Wahl von Elisabeth Baume-Schneider in den Bundesrat eine Ersatzwahl für den hierdurch frei gewordenen Ständeratssitz notwendig gewesen.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 26

Frage 2)

Weiter wird in der Agenturmeldung erwähnt, dass die neue Ständerätin Mathilde Crevoisier Crelier ihre Arbeit als Übersetzerin im Generalsekretariat des EDI aufgegeben habe. Als Angestellte im EDI gehörte sie dem Personal der Bundesverwaltung an. Wäre es ihr rechtlich möglich gewesen, trotz Ständeratsmandat weiterhin im EDI als Übersetzerin tätig zu bleiben? (7 Punkte)

Art. 144 BV schliesst dies nicht aus, doch hält Art. 144 Abs. 3 BV fest, dass das Gesetz weitere Unvereinbarkeiten vorsehen kann. In Art. 14 ParlG werden denn auch weitere Unvereinbarkeiten festgehalten. Art. 14 Bst. c ParlG besagt, dass das Personal der zentralen und dezentralen Bundesverwaltung grundsätzlich nicht der Bundesversammlung angehören darf. Die Bundesversammlung besteht aus National- und Ständerat. Somit musste Mathilde Crevoisier Crelier ihre Funktion innerhalb von sechs Monaten aufgeben; ansonsten hätte sie aus dem Ständerat ausscheiden müssen (Art. 15 Abs. 2 ParlG).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 30 f.

Frage 3)
Könnte ein Kanton vorsehen, dass eine Person ohne Schweizer Staatsbürgerschaft in den Ständerat gewählt werden kann? (3 Punkte)

Nach Art. 150 Abs. 3 BV wird die Wahl in den Ständerat vom Kanton geregelt. Somit wäre es grundsätzlich möglich, im kantonalen Recht vorzusehen, dass Personen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft in den Ständerat gewählt werden können. Art. 136 BV gilt nur für die Nationalrats-, nicht aber für die Ständeratswahlen.

Vgl. BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 28

Frage 4)
Angenommen, Mathilde Crevoisier Crelier hätte viele Freundinnen und Freunde, die gerne einmal bei einer Ständeratssitzung zuschauen möchten. Wäre dies möglich? (3 Punkte)

Ja, die Sitzungen der Räte sind grundsätzlich öffentlich (Art. 158 BV). Ausnahmen von der Öffentlichkeit sind nur in engen Grenzen zulässig und bedürfen einer Grundlage im formellen Gesetz (Art. 158 Satz 2 BV; vgl. Art. 4 Abs. 2 ParlG).

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 80

Frage 5)

Der Kanton Jura mit rund 73'000 Einwohnerinnen und Einwohnern verfügt wie der Kanton Zürich mit rund 1.5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern über zwei Ständeratssitze. Wie lässt sich dies rechtfertigen? (4 Punkte)

Die der föderalistischen Struktur geschuldete Verteilung der Ständeratssitze unabhängig von der Bevölkerungszahl tangiert die demokratische Gleichheit, geht doch die Hälfte der Sitze an eher ländlich geprägte bzw. flächenmässig kleine Kantone (mit anderen politischen Mehrheitsverhältnissen als urbane Kantone), die nur rund einen Fünftel der Gesamtbevölkerung ausmachen.

Der Verfassungsgeber entschied sich aber bewusst für eine solche Regelung. Rechtfertigen lässt sie sich nämlich mit der föderalistischen Gleichheit (Gleichheit der Kantone). Mit Ausnahme der Kantone mit halber Standesstimme (Art. 142 Abs. 4 BV) (früher als «Halbkantone» bezeichnet), die lediglich über einen Ständeratssitz verfügen, besitzen alle anderen Kantone zwei Ständeratssitze, und dies unabhängig von der Einwohnerzahl.

BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, § 18 N. 27

Aufgabe 4: Konzertverbot (30 Punkte)

Eric, ein aufstrebender Rapper, scheut nicht davor zurück, in seinen Liedern Personen zu beleidigen. Hocherfreut preist er seinen neuen Song mit dem Namen «Gerechtigkeit auch für die Armen» auf allen möglichen Kanälen an und sendet ihn an verschiedene Radiostationen und Disco-Besitzer. Doch je bekannter das Lied wird, desto lauter wird auch die Kritik daran. Vor allem stören sich die Politikerinnen und Politiker einer bestimmten politischen Partei, da deren Parteipräsident im Lied als «Extremist», «Volksverhetzer», «hirnloser Idiot» und «geldgieriger Abzocker» bezeichnet wird.

Da Eric so erfolgreich ist, möchte er auf dem Areal des alten Güterbahnhofs der Gemeinde X. ein Konzert für 500 Personen veranstalten, wobei der Eintritt für das Publikum kostenlos sein soll. Beim Konzert möchte Eric neben seinem in die Kritik geratenen Hit weitere neun Songs seines neuen Albums vorsingen. Beim Areal des alten Güterbahnhofs handelt es sich um öffentlichen Grund, der seit vielen Jahren ausschliesslich für Veranstaltungen aller Art (Partys, Konzerte usw.) verwendet wird. Eigentümerin des Areals ist die Gemeinde X. Auch andere Rapperinnen und Rapper veranstalten auf diesem Areal regelmässig Konzerte.

Nachdem Eric beim hierfür zuständigen Gemeinderat (Exekutive der Gemeinde) um die erforderliche Bewilligung gebeten und hierzu die nötigen Informationen eingereicht hatte, erhielt er zwei Tage später ein Antwortschreiben des Gemeinderats und war geradezu schockiert:
Im Antwortschreiben wird Eric eröffnet, dass sein Konzert auf dem Areal des alten Güterbahnhofs gestützt auf Art. 42 des Polizeireglements der Gemeinde X. nicht bewilligt werde. Als Begründung wird angegeben, dass das eine berüchtigte Lied aufgrund seiner Beleidigungen an die Adresse des Parteipräsidenten den Anstand und die Sitte verletze. Ein Lied mit derartigen Beleidigungen könne zudem dazu führen, dass sich das Gemüt des jungen und höchstwahrscheinlich alkoholisierten Publikums derart erhitze, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommen könne. Zwar seien die restlichen neun Songs unproblematisch, dennoch könne aufgrund der verfolgten Null-Risiko-Politik der Gemeinde keine Bewilligung erteilt werden.

Art. 42 des Polizeireglements (= Gemeindegesetz) der Gemeinde X., welches vom zuständigen Gemeindeparlament erlassen worden ist, lautet wie folgt:

Art. 42 Veranstaltungen auf öffentlichem Grund

[1] Veranstaltungen auf öffentlichem Grund bedürfen einer Bewilligung.

[2] Bewilligungen können mit Bedingungen und Auflagen versehen werden.

[3] Verboten sind insbesondere Veranstaltungen:

a. die Anstand oder Sitte verletzen;

b. bei denen mit grosser Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit zu erwarten ist.

Entrüstet meldet sich Eric bei Ihnen. Er ist der Meinung, dass diese Bewilligungsverweigerung seine Grundrechte verletze.

- Prüfen Sie anhand der Prüfkriterien, ob ein Grundrechtsfall vorliegt und ob die Voraussetzungen für die zulässige Einschränkung eines Freiheitsrechts erfüllt sind.
- Gehen Sie bei der Prüfung der Grundrechtsrelevanz auf **zwei Freiheitsrechte der Bundesverfassung** ein, die aus Sicht von Eric im vorliegenden Fall berührt/tangiert sein könnten. Konzentrieren Sie sich bei der nachfolgenden Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung aber auf nur **ein einziges berührtes Freiheitsrecht.**
- **Prüfen Sie alle Kriterien, auch wenn Sie glauben, den Entscheid schon früher treffen zu können.**
- Prozessuale Fragen können Sie weglassen.

Wichtiger Hinweis: Auf die Wirtschaftsfreiheit ist **nicht** einzugehen!

Prüfkriterien 1: Prüfung der Grundrechtsrelevanz

a) Rechtsgrundlagen der Freiheitsrechte

Im vorliegenden Fall könnten die Meinungsfreiheit (Art. 16 BV) und die Kunstfreiheit (Art. 21 BV) berührt sein.

Hinweis: Ebenfalls bepunktet wurden die Versammlungsfreiheit (Art. 22 BV) sowie bei guter Argumentation auch die persönliche Freiheit (Art. 10 BV).

b) Sachlicher Schutzbereich (Schutzobjekt)

Meinungsfreiheit (Art. 16 BV):
Das Recht auf Meinungsfreiheit (Art. 16 Abs. 2 BV) beinhaltet das Recht jeder Person, sich ihre Meinung frei zu bilden und sie ungehindert zu äussern und zu verbreiten. Geschützt sind alle Mittel, die sich zur Kommunikation eignen (Wort, Schrift, Gebärden, künstlerische Formen usw.). Der Begriff der Meinungsfreiheit ist weit zu verstehen. Er umfasst die Gesamtheit der Mitteilungen menschlichen Denkens, auch Informationen ohne wertenden Gehalt (vgl. Art. 16 Abs. 3 BV) und den Ausdruck von Gefühlen. Eine Meinung fällt unabhängig von ihrem Inhalt in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit. Auf die Qualität oder den gesellschaftlichen Wert einer Meinung kommt es grundsätzlich nicht an. Grundrechtlichen Schutz verdienen auch falsche, unaufrichtige und sogar extremistische Äusserungen – also auch Äusserungen, die verletzen, schockieren oder beunruhigen.

In casu: *Eric bezeichnet den Parteipräsidenten als «Extremisten», «Volksverhetzer», «hirnlosen Idioten» und «geldgierigen Abzocker». Damit äussert er seine Meinung über den Parteipräsidenten. Die Begriffe haben zwar einen stark negativen Charakter und können in gewisser Hinsicht als beleidigend aufgefasst werden, erfahren aber trotzdem grundrechtlichen Schutz.*

Fazit: *Der sachliche Schutzbereich der Meinungsfreiheit ist berührt.*

Kunstfreiheit (Art. 21 BV):
Was «Kunst» i.S.v. Art. 21 BV bedeutet, lässt sich nicht abschliessend definieren. Der Kunstbegriff unterliegt den Strömungen des Zeitgeistes; der Verfassungsgeber kann und soll nicht ein für alle Mal festlegen, was «Kunst» ist und was nicht. Geschützt sind alle Formen des Kunstschaffens (Malerei, Bildhauerei, Theater, Tanz, Film, Musik, Literatur, Fotografie, Graffiti usw.), unabhängig von der Art und Weise der Präsentation des Werks. Auch spielt es keine Rolle, ob mit der künstlerischen Tätigkeit kommerzielle Zwecke verfolgt werden oder nicht.

In casu*: Ein Rap-Song fällt unter die Sparte Musik und stellt zweifelsohne eine Form der Kunst dar.*

Fazit*: Der sachliche Schutzbereich der Kunstfreiheit ist berührt*

Hinweis: *Die Meinungsfreiheit (Art. 16 BV) und die Kunstfreiheit (Art. 21 BV) (sowie ebenfalls die Versammlungsfreiheit [Art. 22 BV]) gehören zu den Kommunikationsgrundrechten. Diese können häufig nur in der Öffentlichkeit sinnvoll ausgeübt werden. Deshalb vermitteln die Kommunikationsgrundrechte einen Anspruch auf Benutzung des öffentlichen Grundes, den das Bundesgericht als Leistungsanspruch qualifiziert. Zum öffentlichen Grund zählen alle der Allgemeinheit offenstehenden Flächen, insbesondere Strassen und Plätze, aber auch etwa Gemeindesäle. Soweit es um eine Nutzung geht, die – wie das Sammeln von Unterschriften auf öffentlichen Strassen und Plätzen – bestimmungsgemäss und gemeinverträglich ist (sog. Gemeingebrauch), besteht ein «unbedingter» Anspruch auf Benutzung des öffentlichen Grundes. Handelt es sich um eine intensivere Nutzung (sog. gesteigerter Gemeingebrauch) – wie etwa die Durchführung einer Demonstration – ist der Anspruch «bedingt»: Es besteht kein Anspruch auf Nutzung eines beliebigen Ortes zu einer beliebigen Zeit zu diesem Zweck; zudem ist beim Entscheid nicht nur der Schutz der Polizeigüter, sondern auch das Interesse der Allgemeinheit an einer bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlichen Grundes zu berücksichtigen. Solche intensiveren Formen der Benutzung dürfen, anders als der Gemeingebrauch (BGE 135 I 302, E. 4), einer Bewilligungspflicht unterworfen werden. Das Bewilligungserfordernis stellt, ebenso wie die Ablehnung eines Bewilligungsgesuchs, eine Grundrechteinschränkung dar.*

In casu*: Aufgrund der Tatsache, dass das Areal des alten Güterbahnhofs in öffentlicher Hand ist und seit vielen Jahren als Veranstaltungsort dient, handelt es sich um eine öffentliche Sache im Gemeingebrauch. Eric möchte ein Konzert veranstalten, was als gesteigerter Gemeingebrauch zu qualifizieren ist.*

Fazit: *Das Gesagte hat zur Folge, dass eine Bewilligungspflicht grundsätzlich zulässig ist und eine Ablehnung des Bewilligungsgesuchs den sachlichen Schutzbereich der oben genannten Freiheitsrechte tangiert.*

c) Persönlicher Schutzbereich (Grundrechtsträgerschaft)

Die Kommunikationsgrundrechte stehen allen Personen zu: natürlichen und juristischen, ausländischen und schweizerischen, minderjährigen und volljährigen.

In casu*: Eric ist eine natürliche Person.*

Fazit: *Eric ist Träger sämtlicher oben genannter Freiheitsrechte.*

d) Adressat

Adressat der beiden Freiheitsrechte ist der Staat bzw. sind die staatlichen Behörden auf allen Ebenen der staatlichen Tätigkeit (Bund, Kantone, Gemeinden).

In casu: *Beim Gemeinderat der Gemeinde X. handelt es sich um eine staatliche Behörde auf Ebene Gemeinde.*

Fazit: *Der Gemeinderat der Gemeinde X. ist Adressat der hier diskutierten Grundrechte.*

e) Zwischenergebnis der Vorprüfung

Es liegt ein Grundrechtsfall vor.

Prüfkriterien 2: Prüfung der Zulässigkeit der Einschränkung (Art. 36 BV)

a) Gesetzliche Grundlage

Art. 36 Abs. 1 BV
Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage. Eine Ausnahme bildet die polizeiliche Generalklausel (Fälle ernster, unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr).

Gemäss Art. 42 Abs. 3 des Polizeireglements der Gemeinde X. sind insbesondere Vorführungen und Handlungen aller Art, die Anstand oder Sitte verletzen (Bst. a) oder bei denen mit grosser Wahrscheinlichkeit eine erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit zu erwarten ist (Bst. b), verboten.

Erfordernis des Rechtssatzes

- *Die Freiheitsbeschränkung muss grundsätzlich in einem Rechtssatz, d.h. in einer generell-abstrakten Norm, vorgesehen sein (Art. 22 Abs. 4 ParlG). Generell ist eine Norm, wenn sie sich an eine unbestimmte Zahl von Adressatinnen und Adressaten richtet, abstrakt ist eine Norm, wenn sie eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt.*
- *Der Rechtssatz muss überdies genügend bestimmt sein, d.h. er muss so präzise formuliert sein, dass die Bürgerinnen und Bürger ihr Verhalten danach richten und die Folgen eines bestimmten Verhaltens mit einem entsprechenden Grad an Gewissheit erkennen können.*

In casu: *Art. 42 des kommunalen Polizeireglements stellt eine generell-abstrakte Norm dar, da er sich an eine unbestimmte Zahl von Adressatinnen und Adressaten richtet und eine unbestimmte Vielzahl von Fällen regelt.*
Art. 42 des kommunalen Polizeireglements ist jedoch unter dem Gesichtspunkt der Bestimmtheit in vielerlei Hinsicht problematisch:
Die Aufzählung sowohl in Abs. 3 Bst. a als auch in Bst. b ist sehr offen formuliert und sehr auslegungsbedürftig, was zu einem grossen Ermessenspielraum des Rechtsanwenders führt. Während Bst. b wohl gerade noch als genügend bestimmt angesehen werden kann, ist die Regelung in Bst. a problematisch. So wird nirgends definiert, was alles den Anstand oder die Sitte verletzt. Der Anstand und die Sitte sind zwei völlig unbestimmte Rechtsbegriffe, die eine massgebliche subjektive Komponente aufweisen. Der Begriff der Sittlichkeit hängt, wie derjenige der öffentlichen Ordnung überhaupt, in starkem Masse von den herrschenden sozialen und moralischen Anschauungen ab. Er ist deshalb örtlich verschieden und zeitlich wandelbar. So können Handlungen oder Äusserungen von einem Teil der Bevölkerung als in Ordnung angesehen werden, während ein anderer Teil der Bevölkerung dieselben als den Anstand oder die Sitte verletzend einstufen würde. Eine genauere Umschreibung der beiden unbestimmten Rechtsbegriffe wäre also angebracht gewesen.
Am schwersten wiegt jedoch die Tatsache, dass die Aufzählung nicht abschliessend zu sein scheint, was mit dem Wort «insbesondere» im Gesetzestext zum Ausdruck kommt. Das heisst, dass die Bewilligungsbehörde frei ist, Veranstaltungen aus Gründen zu verbieten, die nicht in Art. 42 Abs. 3 des Polizeireglements vorgesehen sind.

Zwischenfazit Erfordernis des Rechtssatzes*: Dieses Erfordernis ist nicht erfüllt.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wird, sofern rechtlich korrekt begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Erfordernis der Gesetzesform
Schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein, d.h. in einem Gesetz im formellen Sinn (Art. 36 Abs. 1 Satz 2 BV). Nicht schwerwiegende Grundrechtseinschränkungen können auch in Erlassen niedrigerer Stufe vorgesehen sein, insbesondere in einer Verordnung.

In casu: *Art. 42 des kommunalen Polizeireglements wurde vom zuständigen Gemeindeparlament erlassen. Beim Polizeireglement handelt es sich um ein Gesetz auf Stufe Gemeinde. Folglich stellt Art. 42 des kommunalen Polizeireglements eine formell-gesetzliche Grundlage dar, weshalb insoweit die Schwere des Grundrechtseingriffs unerheblich ist.*

Zwischenfazit Erfordernis der Gesetzesform*: Dieses Erfordernis ist erfüllt.*

Gesamtfazit gesetzliche Grundlage:
Das Erfordernis des bestimmten Rechtssatzes ist nicht erfüllt. Art. 42 stellt demnach, obwohl das Erfordernis der Gesetzesform erfüllt ist, keine hinreichende gesetzliche Grundlage für die Einschränkung der Freiheitsrechte dar.

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wird, sofern rechtlich korrekt begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

b) Rechtfertigende Eingriffsinteressen

Art. 36 Abs. 2 BV
Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

Im öffentlichen Interesse liegt alles, was der Staat zum Gemeinwohl vorkehren muss, um eine ihm obliegende Aufgabe zu erfüllen. Als hinreichendes öffentliches Interesse gilt etwa der Schutz der Polizeigüter (Ruhe und Ordnung, öffentliche Sicherheit, öffentliche Gesundheit, öffentliche Sittlichkeit, Treu und Glauben im Geschäftsverkehr). Weitere öffentliche Interessen ergeben sich aus der Bundesverfassung und der Gesetzgebung. Das Eingriffsinteresse des Schutzes von Grundrechten Dritter macht deutlich, dass die Grundrechtsansprüche verschiedener Grundrechtsträger miteinander kollidieren können.

In casu: *Das öffentliche Interesse besteht vor allem darin, die öffentliche Sicherheit sowie die Ruhe und Ordnung zu gewährleisten. Es soll verhindert werden, dass Eric eine Bühne gegeben wird, die er nutzt, um den Parteipräsidenten öffentlich zu beleidigen. Zudem soll verhindert werden, dass es als Folge der Beleidigung zu gewaltsamen Ausschreitungen kommt. Auch wenn das Risiko von Ausschreitungen im konkreten Fall gering sein dürfte, so kann das öffentliche Interesse dennoch bejaht werden.*
Zudem lässt sich die Ansicht vertreten, dass mit dem Schutz der öffentlichen Sittlichkeit ein weiteres öffentliches Interesse eine Rolle spielen könnte, auch wenn der Begriff der öffentlichen Sittlichkeit höchst unbestimmt und in hohem Masse auslegungsbedürftig ist.

Zusätzlich könnte man ins Feld führen, dass auch Grundrechte des Parteipräsidenten zu schützen seien. Hierfür müsste dargelegt werden, dass die Beleidigungen einen Eingriff in die persönliche Freiheit (Art. 10 BV) des Parteipräsidenten darstellen.

***Fazit:** Es liegen rechtfertigende Eingriffsinteressen vor.*

c) Verhältnismässigkeit

Art. 36 Abs. 3 BV
***Eignung:** Die Massnahme muss geeignet sein, den angestrebten Zweck zu erreichen.*

***In casu**: Die komplette Nichtbewilligung des Konzerts ist ohne weiteres geeignet, den angestrebten Zweck zu erreichen.*

***Fazit:** Die Eignung ist gegeben.*

***Erforderlichkeit**: Die Massnahme muss den geringstmöglichen Eingriff darstellen; es darf keine gleichermassen geeignete, mildere Massnahme geben, die zum gleichen Ziel führen würde. Der Eingriff darf in sachlicher, räumlicher, zeitlicher und personeller Beziehung nicht über das Notwendige hinausgehen.*

***In casu**: Die vom Gemeinderat ausgesprochene Bewilligungsverweigerung wird aus Art. 42 Abs. 2 des Polizeireglements der Gemeinde X. abgeleitet. Es wäre aber ohne weiteres möglich gewesen, die Bewilligung mit der Auflage zu erteilen, ein Sicherheitskonzept zu erstellen bzw. Sicherheitsleute zu engagieren, um die öffentliche Sicherheit bestmöglich zu gewährleisten. Weiter erscheint es stossend, aufgrund eines einzigen Songs, der als problematisch erachtet wird, ein ganzes Konzert zu verbieten. Der Gemeinderat gibt in seiner Begründung sogar zu, dass die anderen neun Lieder unproblematisch seien. Selbst wenn man die Ansicht vertreten würde, dass dieses eine Lied inhaltlich zu problematisch wäre, so hätte man immerhin die Bewilligung mit der Auflage erteilen können, dass dieses eine Lied nicht gespielt werden darf.*
Es hätte somit zweifelsohne mildere Massnahmen gegeben. Die Bewilligungsverweigerung des Gemeinderats geht somit in sachlicher Beziehung über das Notwendige hinaus.

***Fazit:** Die Erforderlichkeit ist nicht gegeben.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

***Zumutbarkeit:** Die Massnahme darf zu keinem Missverhältnis zwischen Eingriffszweck und Eingriffswirkung führen (Zweck-Mittel-Verhältnis). Das öffentliche Interesse an der Einschränkung des Grundrechts muss das private Interesse an dessen ungehinderter Ausübung überwiegen.*

In casu (inkl. Abwägung):
Öffentliches Interesse an der Einschränkung: siehe oben.
Schutz von Grundrechten Dritter: siehe oben.
*Privates Interesse**:** Interesse von Eric, sein Konzert zu veranstalten.*
Das öffentliche Interesse, öffentliche Beleidigungen und gewaltsame Ausschreitungen zu verhindern, ist zwar gewichtig. Das Risiko, dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen kommt, ist aber als eher gering

einzustufen. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Zuschauer aufgrund beleidigender Aussagen gegen den Parteipräsidenten sofort zum Mittel der Gewalt greifen würden, zumal die Beleidigungen im Vergleich zu den Texten anderer Rap-Songs geradezu harmlos sind. Überdies gilt es zu beachten, dass politische Äusserungen für den demokratischen Meinungsbildungsprozess eine besondere Bedeutung haben und die Anforderungen an das Vorhandensein überwiegender Eingriffsinteressen hoch sind. Was die Beleidigungen anbelangt, so gilt es festzuhalten, dass sich der Parteipräsident als Person des öffentlichen Lebens mit relativer Bekanntheit mehr als eine durchschnittliche Bürgerin oder ein durchschnittlicher Bürger gefallen lassen muss. Zudem lässt sich durchaus vertreten, dass die Äusserungen von Eric einen politischen Gehalt aufweisen und demnach einen erhöhten Schutz geniessen. Die harte Sanktionierung (komplette Bewilligungsverweigerung) durch den Gemeinderat ist für Eric entsprechend unzumutbar.

***Fazit:** Die Zumutbarkeit ist nicht gegeben.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

***Zwischenergebnis Verhältnismässigkeit**: Die Verhältnismässigkeit der Einschränkung ist im gegebenen Fall zu verneinen.*

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

d) Schutz des Kerngehalts, falls die Meinungsfreiheit gewählt wurde

Art. 36 Abs. 4 BV
In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Grundrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.
Zum Kerngehalt der Meinungsfreiheit gehört die in Art. 16 Abs. 2 BV angesprochene Freiheit, sich eine Meinung zu bilden (und eine solche zu haben). Absolut verboten sind somit staatliche Massnahmen, die Menschen zur inneren Identifikation mit einer Meinung zwingen (z.B. durch Gehirnwäsche oder den Einsatz von Psychopharmaka).

***In casu:** Die Bewilligungsverweigerung fällt nicht unter den Kerngehalt der Meinungsfreiheit.*

***Fazit:** Der Kerngehalt der Meinungsfreiheit ist gewahrt.*

d) Schutz des Kerngehalts, falls die Kunstfreiheit gewählt wurde

Art. 36 Abs. 4 BV
In den Kerngehalt eines Grundrechts darf unter keinen Umständen eingegriffen werden. Ein Grundrecht darf weder völlig unterdrückt noch seines Gehalts als fundamentale Institution der Rechtsordnung entleert werden.
Der Kerngehalt der Kunstfreiheit wurde bislang vom Bundesgericht noch nicht konkretisiert. In der Lehre wird davon ausgegangen, dass die systematische präventive inhaltliche Zensur darunterfällt.

In casu: *Die Bewilligungsverweigerung fällt nicht unter den Kerngehalt der Kunstfreiheit, zumal aufgrund des Sachverhalts nicht von einer systematischen, präventiven inhaltlichen Zensur ausgegangen werden kann.*

Fazit: *Der Kerngehalt der Kunstfreiheit ist gewahrt.*

e) Gesamtergebnis

Die Bewilligungsverweigerung stellt einen unzulässigen Eingriff in die Grundrechte von Eric dar.

Anmerkung: Die gegenteilige Ansicht wurde, sofern überzeugend begründet, ebenfalls mit voller Punktzahl bewertet.

Vgl. zum Ganzen BIAGGINI/GÄCHTER/KIENER, *§§ 30, 31, 32, 34 und 37*